

1501258-22.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RODRIGO MARCOS DE ALMEIDA GERALDES

Comarca: Francisco Morato

Foro: Foro de Francisco Morato

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2128716/2022 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 24912750 -

DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 2128716 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

JOSE HENRIQUE AVIAN

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Francisco Morato

Foro de Francisco Morato

2ª Vara

Rua João Mendes Júnior, 626, Francisco Morato-SP - cep 07910-220

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501258-22.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501258-22.2022.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2128716/2022 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 24912750 -

DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 2128716 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

JOSE HENRIQUE AVIAN

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RODRIGO MARCOS DE ALMEIDA GERALDES

Vistos.

JOSE HENRIQUE AVIAN foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, porque, no dia 11 de maio de 2022, no período da manhã, na Rua Humberto de Campos, nº 33, Jardim dos Bandeirantes, neste município e comarca, nas imediações do estabelecimento de ensino "Escola Municipal

Manuel Bandeira", trazia consigo, para fins de tráfico, 24 (vinte e quatro) eppendorffs de cocaína, 51 (cinquenta e uma) porções de maconha e 70 (setenta) papé debates de crack, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, quando foi surpreendido e preso em flagrante.

A denúncia foi recebida em 01 de junho de 2022 (fls. 86/87). O réu foi citado (fls. 118) e apresentou resposta à acusação (fls. 136/140). Ratificação do recebimento da denúncia às fls. 165/166.

Em regular instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia e três pela defesa. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público, entendendo provadas a materialidade e autoria, insistiu na condenação proposta, pugnando pela aplicação da pena acima do mínimo legal em virtude da reincidência e da quantidade de drogas apreendida.

A Defesa, por sua vez, pugnou em memoriais pela absolvição com fulcro no art. 386, V e VII do CPP. Na hipótese de condenação, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, com substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO

A ação merece ser julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A materialidade delitiva restou comprovada diante do auto de exibição e apreensão de fls. 14, do laudo de constatação provisória de entorpecente com fotografias de fls. 18/23, do laudo de exame químico toxicológico definitivo de fls. 73/75 e, por fim, pela prova oral colhida em regular instrução.

Da mesma forma, a autoria é indubitosa diante do conjunto probatório apresentado nos autos do caso sub judice, apontando a prática do delito de tráfico ao acusado.

Quando por ocasião de sua prisão em flagrante, o réu se reservou ao direito de se manifestar tão somente em juízo (fls. 7).

Já em seu interrogatório judicial, negou por completo a prática dos fatos narrados na denúncia. Disse que é usuário de drogas e que teve uma recaída à época. No dia, foi ao local comprar drogas e os "meninos" que estariam vendendo correram, ao que os policiais resolveram abordar o interrogando. Nega a propriedade da droga e disse que jamais poderia ser traficante, já que é usuário compulsivo. Já esteve internado vários vezes pelo vício. Disse, ainda, que já foi abordado pelos policiais outras vezes, tendo inclusive apanhado e recebido a promessa de que um dia eles iriam imputar drogas ao interrogando.

Todavia, os demais elementos dos autos não indicam que os fatos se sustentam tais como narrados pelo réu. Senão vejamos.

As testemunhas e policiais civis Alexandre e Abel, narraram, de forma coerente e clara, que, no dia dos fatos, foram ao local dos fatos, que é um ponto de venda de drogas que é usualmente objeto de reclamações de moradores do entorno. Chegaram lá à paisana e em viaturas descaracterizadas e viram o réu com uma sacola na mão. Ele foi abordado e de pronto admitiu que estava ali traficando. Na sacola os depoentes localizaram os entorpecentes apreendidos, bem como a quantia de R\$ 125,00 e um rádio comunicador HT. Recordaram-se que o réu foi abordado outras vezes, mas não foi detido porque não estava em situação de interesse policial. Antonio falou que possivelmente havia gente por perto quando da abordagem, mas que ninguém foi qualificado. Abel adicionou que, nestas situações, as pessoas em volta costumam entrar em casa e não se envolver na diligência policial.

Não há razão para desqualificar a prova policial, pois não há qualquer dado que afaste a natural credibilidade de que gozam tais testemunhas. São agentes do Estado, razão pela qual seus depoimentos devem ser avaliados sob a perspectiva da presunção de credibilidade, a menos que infirmados por outros elementos de convicção. A narrativa tecida por ambos é coesa, coerente, uniforme e detalhada. É o suficiente para lhes conferir importante valor probatório. No mesmo sentido, converge a lição diária de nossos tribunais:

Prova criminal - Testemunhal - Tráfico de entorpecentes - Depoimentos de policiais que efetuaram a apreensão - Credibilidade - Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador. (ACR 147980, Rel: Jarbas Mazzoni).

"o valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - 1ª Turma - HC 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

A testemunha Israel relatou que mora próximo ao local e que, no dia dos fatos, os "moleques" que estariam vendendo drogas ali correram e largaram tudo para trás, ao passo que o réu, que estaria indo ao bar, foi abordado. Disse que isso se deu por volta das 11h15min e que visualizou o ocorrido por estar no quintal. Conhece o réu por ele morar ali perto e frequenta o mesmo bar que ele. Assevera que o réu é dependente e estava só passando. Declara que são sempre pessoas diferentes a vender drogas no local, mas que conhece. Disse, ainda, que não foi à delegacia passar sua versão dos fatos.

Já Janaína identificou-se como dona do bar ao redor e disse que conhece o réu por ele morar ali perto. No dia, o réu comprou um doce no bar e saiu, momento em que os "meninos" saíram correndo e o réu ficou, tendo sido abordado. Declara que os policiais "jogaram" drogas em cima do réu, que estaria ali só para comprar entorpecentes. É dona do bar há 6 meses e declara ter ciência de que há comércio de entorpecentes nas redondezas.

A testemunha de defesa Marta nada sabia sobre os fatos e pouco esclareceu a respeito do ocorrido.

O réu não trouxe aos autos qualquer indício mínimo de prova de que os fatos não se deram da forma narrada na denúncia, ônus que lhe incumbia por força do art. 156 do Código de Processo Penal.

A versão das testemunhas Israel e Janaína são de duvidosa credibilidade. Ambos depuseram juntos, no mesmo local, e indicaram que conhecem o réu porque todos convivem no mesmo bar.

No entanto, ainda que tenham visto - sempre na versão deles - o réu passar por uma situação de extrema injustiça, já que policiais teriam imputado injustamente a posse de drogas ao acusado, estranhamente omitiram-se de declarar o que viram à autoridade policial e somente em juízo apareceram para se dizerem testemunhas presenciais dos fatos.

Outrossim, a tese de que os policiais "forjaram" o flagrante não se sustenta com o histórico que os envolve em relação ao réu.

Com efeito, os policiais admitiram que conheciam o réu de abordagens anteriores - o que o próprio admitiu -, mas que não o conduziram ou detiveram nestas ocasiões porque com ele nada de ilícito foi encontrado. Ou seja, não há qualquer prova de animosidade prévia e de disposição de que tivessem nesta oportunidade imputado ao réu conduta não praticada efetivamente.

O crime de tráfico ilícito de drogas é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas uma na outra desde a sua produção até a sua entrega a consumo, ainda que de forma gratuita. A quantidade de droga apreendida era relevante e se mostra suficiente, dentro do contexto probatório, para colocar em risco a saúde pública e a segurança da comunidade.

Por fim, vale consignar que o decreto condenatório não se ampara exclusivamente nos depoimentos colhidos em sede administrativa, e sim em todo o contexto probatório, corroborando a prova produzida em juízo a sucessão de fatos tal como foram apurados e narrados em sede policial, todos coesos no mesmo sentido.

Todavia, não se vislumbra razão para a aplicação no caso em tela da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006.

Isso porque não há comprovação de que o réu tivesse ciência da proximidade de uma escola ou, mais, que se valesse de tal circunstância para assim amealhar possíveis compradores para os entorpecentes.

Dosimetria da pena

Passo a dosar a pena, de acordo com o critério trifásico que informa o Código Penal.

- a) Na primeira fase da dosimetria da pena, observando os critérios do art. 59 do Código Penal, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, considerando que a quantidade de entorpecente apreendida evidencia um considerável potencial de disseminação da droga no seio da comunidade. Outrossim, o réu ostenta maus antecedentes. Assim, a pena-base resulta em: 6 anos de reclusão e 600 dias-multa para o crime em análise;
- b) Na segunda fase, incide a circunstância agravante da reincidência, em mais de uma ocorrência (fls. 111/115), a qual deverá gerar um acréscimo de 1/5 nas penas antes fixadas, que assim montam em 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e 720 dias-multa;
- c) Na terceira fase, em vista da condenação anterior, não incide a causa especial de redução do art. 33, §4º da Lei 11.343/06. O dispositivo objetiva punir menos severamente apenas aquele que está se inserindo na criminalidade, e não aquele já embrenhado em tal prática. Por tal razão, não há que se reconhecer a causa especial de redução aludida;
- d) O regime de cumprimento é o inicialmente fechado, na forma do parágrafo primeiro do art. 2º da Lei 8.072/90;
- e) A despeito do teor da Resolução n. 5, de 16 de fevereiro de 2012, do Senado Federal, permanece inviável a substituição por pena alternativa porque é incompatível a benesse prevista para crimes de pequeno potencial ofensivo, não se mostrando suficiente para as finalidades da sanção penal (art. 44, inciso III, do Código Penal).
- f) Inaplicável a suspensão condicional da pena, diante das circunstâncias do caso concreto, as quais apontam que tal medida não é socialmente recomendável.

Dispositivo

Diante do exposto e tudo mais do que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra o réu JOSÉ HENRIQUE AVIAN e o CONDENADO ao cumprimento de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 720 dias-multa, calculada a unidade no mínimo legal, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Em que pese a alteração legislativa levada a efeito com a publicação da Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, em especial da redação do seu art. 1º e 2º, deixo de aplicá-la em sua integralidade.

Ora, trata-se de dispositivos manifestamente inconstitucionais, posto que violam os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia.

O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena.

A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória.

Na primeira, caberá à lei fixar as penas que serão aplicadas para cada tipo penal. A quantidade da pena deve guardar proporção com a importância do bem jurídico tutelado e a gravidade da ofensa. Por isso, cada tipo penal prevê quantidade mínima e máxima de pena e, em alguns casos, espécies distintas de sanções penais, que podem ser aplicadas, dependendo do caso, alternativa ou cumulativamente.

Na etapa judiciária, caberá ao juiz, à vista da infração cometida, escolher a pena que será aplicada dentre as cominadas no tipo penal, dosar a sua quantidade entre o mínimo e máximo previsto, fazer inserir causas que possam aumentar ou diminuir a reprimenda, fixar o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como analisar possível substituição por pena mais branda.

Cuida-se de critério em que o julgador possui discricionariedade regrada. Isso porque, embora tenha liberdade de escolha quanto à pena que irá aplicar, bem como sua quantidade, deve obediência a regras previstas no Código Penal.

Por fim, após a aplicação da pena, há necessidade de sua execução. As diretrizes quanto à execução da pena estão previstas principalmente no Código Penal e na Lei das Execuções Penais.

A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: "A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão".

Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena.

A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais,

que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença.

Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea "b", da Lei das Execuções Penais.

E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia.

Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, "caput", da CF).

Deve o réu aguardar eventual recurso custodiado, tendo em vista que respondeu a todo o processo nesta condição e, inalteradas as circunstâncias, persistem presentes os requisitos que ensejaram a prisão processual, especialmente após a condenação.

Após trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral.

Declaro o perdimento da quantia em dinheiro apreendidos com o réu, a qual certamente provém da atividade ilícita acima analisada.

P.I.C.

Francisco Morato, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA